



Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

RESOLUCIÓN N° 000411-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA

Expediente : 00197-2023-JUS/TTAIP
Recurrente : **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**
Entidad : **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**
Sumilla : Declara fundado recurso de apelación

Miraflores, 6 de febrero de 2023

VISTO el Expediente de Apelación N° 00197-2023-JUS/TTAIP de fecha 23 de enero de 2023, interpuesto por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra el Oficio N° 153 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, por el cual el **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** denegó su solicitud de acceso a la información pública presentada con fecha 28 de diciembre de 2022 con Registro 0000420323¹.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2022, el recurrente solicitó a la entidad la entrega por correo electrónico de la siguiente información:

“Tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre en Pichanaki (Junín), en el marco del DS 143-2022-PCM”.

Mediante el Oficio N° 153 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023 la entidad denegó dicho pedido alegando lo siguiente:

“Al respecto, su requerimiento fue solicitado con Memorándum N° 825 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 29 de diciembre de 2022, obteniendo como respuesta el Memorándum N° 025 ECMFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, mediante el cual el Jefe de División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señala: “(...) es información que está exceptuada de ser público, según lo establecido en el artículo 15°.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, (...)”; por

¹ Encausa a la entidad por el Ministerio de Defensa mediante el Oficio N° 00645-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022.

lo tanto, de acuerdo a lo descrito anteriormente, no es viable atender a su requerimiento.”

Con fecha 23 de enero de 2023, el recurrente interpuso el recurso de apelación materia de análisis contra la referida comunicación, señalando que la información solicitada es reportada por los miembros de las Fuerzas Armadas conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1095, y además que su divulgación permite fiscalizar la labor de dichos miembros en el marco de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ayacucho, Apurímac y Junín, por lo cual no podrá ser considerada como información clasificada.

Mediante la RESOLUCIÓN N° 000296-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 25 de enero de 2023, notificada a la entidad en fecha 30 de enero de 2023, esta instancia le solicitó la remisión del expediente administrativo correspondiente y la formulación de sus descargos.

Mediante el Oficio N° 517 CCFFAA/SG/UAIP recibido por esta instancia en fecha 2 de febrero de 2023, la entidad indicó lo siguiente:

“Por lo tanto. con Memorándum N° 822 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 29 de diciembre de 2022, se realizó el requerimiento del ciudadano en mención, obteniendo como respuesta el Memorándum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, mediante el cual el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. señala (...) pedidos de información efectuados por el ciudadano Ernesto CABRAL Mejía, siendo que lo solicitado es información que está exceptuada de ser público, según lo establecido en el Artículo 15°.- Excepciones al ejercicio del derecho: información Secreta del TUO de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (...). En tal sentido por medio del cual se da a conocer al administrado que, de acuerdo a la normatividad anteriormente citada, no es viable atender o su requerimiento.

Asimismo, con Memorándum N° 101 CCFFAA/SG/UAIP de fecha de 30 de enero de 2023, se solicitó un informe explicativo a la División de Operaciones frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, referente a los motivos por los cuales. no se brindó la información solicitada por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, obteniendo como respuesta el Memorándum N° 083 EMCFFAA/D 3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, mediante el cual el jefe de la citada División, remite el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, detallando y justificando los motivos por los cuales no era viable la entrega de la información solicitada por el administrado.”

Además, consta en autos el Memorándum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI, que indica:

“(…)

2. Al respecto, dichos memorándums se refieren o pedidos de información efectuados por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, siendo que lo solicitado es información que esta exceptuada de ser público, según lo establecido en el Artículo 15°.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; motivo por el cual, las solicitud es en mención no proceden.”

A su vez, consta el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI, que refiere:

“(...)

3.- En ese sentido, en lo que se refiere el recurso de apelación interpuesto por Ernesto Alonso CABRAL MEJÍA, contra la respuesta contenida en el Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP, a través del cual el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) atendió la solicitud de acceso a la información pública reencausada mediante el Oficio N° 00645-2022-MINDEL/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre de 2022. en primer término, se debe referir que dentro de la información (tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las FFAA en Huamanga, Andahuaylas y Pichanaki en el marco del D.S. T 43-2022- PCM) que el indicado ciudadano peticionó se encuentra información que no posee carácter de información pública, o dicho en otros términos dentro de las excepciones al derecho de acceso, en aplicación debida e irrestricta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 27806.

4.- Lo anteriormente referido se encuentre taxativamente expuesto en el numeral 45.7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095: Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, que a la letra establece: "Los pedidos de información o documentación sobre una operación y acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública."

5.- Resulta innegable que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que consagra la Constitución Política del Perú; sin embargo, la propia Constitución Política establece las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por, ley o por razones de seguridad nacional (conforme al numeral 5 del artículo 2 de la norma constitucional).

6.- En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública ha sido desarrollado a través, actualmente, del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con D.S. 02 -2019-JUS, normativa que entre otros señala las situaciones de excepciones oí derecho de acceso a información.

7.- Como ya se ha mencionado el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 2.5 de la Constitución de 1993. sin embargo, el acceso a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) tiene sus "Límites", excluyéndose aquella cuyo acceso público se encuentra prohibido por la Constitución, es decir, entre otras lo Información que afecte la seguridad nacional. En ese contexto, las citadas excepciones han sido desarrolladas por los artículos 15º, 6º y 17º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, normativa concordante a lo dispuesto en la Directiva General N° 01-2012-DE/SG "Normas para garantizar la Seguridad de las Informaciones en el Ministerio de Defensa" y la Directiva N° 022- 21/JCCFFAA/SJ "NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO CLASIFICACIÓN, ARCHIVO Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION EN EL COMANDO CON JUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS".

8.- No obstante, la información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Para estos efectos. el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora.

9.- Es así, que existe la autorización legal para que parte de la información que posean las Entidades del Estado, en este caso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armados, sea considerada dentro de las excepciones previstas en la normativa aplicable, por lo que en lo relacionado a lo petición denegada que es

materia de apelación, se ha dado estricto cumplimiento a lo que establece la Constitución y las Leyes.

10.- Como se indicó en su oportunidad, la información requerida por el peticionante tiene la condición de clasificada dentro de las excepciones de ley, dado que se establecen en ellas, documentación o información, cuyo objetivo es el lograr el restablecimiento y mantenimiento del orden interno, en acciones militares en apoyo al misionamiento constitucional de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de un Estado de Emergencia que a la fecha continua en algunos lugares del territorio nacional.

11.- Resulta lógico y necesario entonces que, en salvaguarda del éxito de las acciones en apoyo o la misión constitucional de mantener y restablecer el orden interno de nuestra gloriosa Policía Nacional, esta documentación e información tengan un carácter y condición de clasificadas y reservadas, como para hacerse de conocimiento público per se.

12.- Este carácter de clasificados de los documentos, disposiciones e información, como es de conocimiento público, no es absoluto, ni va en contra de la capacidad fiscalizadora que posee la ciudadanía, sino que dicha capacidad se encuentra focalizada o dirigida por ciertas autoridades a quienes, de ser requeridas, se da acceso a la misma, por lo que estamos ante una situación en la que no se encuentra autorizado la entrega de la información requerido a parte de la población.

13.- Se entiende ello, en el sentido que la difusión de dichos documentos e Información, implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el manteniendo del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno, que como es sabido viene siendo violentado por un grupo de personas, que una vez identificados, serán denunciados y procesados por el daño que vienen ocasionando al propio Establo, a las personas y a los bienes.

14.- En este caso, la eficacia y eficiencia de las acciones devienen de su buena ejecución y carácter de reservado, en la obtención del objetivo deseado, siendo que su difusión y entrega signifique un riesgo latente en contrario.

15.- Es pertinente, resaltar que la excepción de acceso a dicha información se basa en estricto y exactamente en las normativas nacionales del caso, que claramente conoce el peticionante y sus abogados, que a su vez tiene sustento en normas y estándares internacionales que regulan el empleo y uso de la fuerza, a los cuales se da el debido y estricto cumplimiento.

16.- En cuanto a la supuesta falta de precisión de la excepción de la información solicitado, basta la lectura del artículo 16 del TUO de la ley 27806 (se pone en negrita la que corresponde], que a la letra establece:

“Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia, se considera reservado la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente o ellos.

b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley. incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

f) La información contenida en los Reportes de actividades con las sustancias químicas tóxicas y sus precursores listados en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción: la información contenida en los Reportes sobre las instalaciones de producción de las sustancias químicas orgánicas definidas: la información relacionada con las inspecciones nacionales e inspecciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas: la información concerniente a los procesos productivos en donde intervienen sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de dicha Convención; y la información concerniente al empleo de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1 y 2 de dicha Convención".

No existe duda alguna, que lo peticionado resulta ser visible y notoriamente relacionado a lo que establece la excepción descrita.

17.- Lo señalado en el párrafo anterior, también se encuentra regulado y previsto en la Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa, la cual dentro de su anexo "1", sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información RESERVADA según el literal d) del artículo 16 de la ley de la materia, dispone:

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia, se considera reservada la Información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

01: Adquisición, provisionamiento de armamento, munición y artificios para su empleo en régimen de excepción.

05: Informe de consumo de munición de la Institución.

18.- Del mismo modo, Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la cual dentro de su anexo "1", sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información secreto según el literal e) del artículo 16 de la ley de la materia, dispone:

03: Adquisición, provisionamiento de armamento, munición y artificios para su empleo en régimen de excepción.

05: Informe de consumo de munición de la Institución.

19.- No puede suponerse menos afirmarse, como temerariamente expresa el peticionante, que las Fuerzas Armadas han cometido actos de violación de Derechos Humanos.

20.- Cabe agregar, que deben ser rechazadas tajantemente las aseveraciones sobre que los lamentables fallecimientos acaecidos durante los actos de movilización social en diferentes partes del territorio nacional, que en algunos casos han devenido en actos vandálicos y de otros de connotación delictiva, pues dichas lamentables y sensibles pérdidas, vienen siendo investigados por la autoridad competente conforme es de conocimiento público y que cito el propio peticionante.

21.- Estas afirmaciones, no solo son dañosas para la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, sino que también van en contra de la presunción de inocencia que gozan todos los ciudadanos de la Nación, dentro de las que se incluyen las fuerzas del orden. citar publicaciones de medios de comunicación no prueban de modo alguno tales aseveraciones y afirmaciones, lo cual deberá ser evaluado por las instancias correspondientes para las acciones administrativas o legales que pudieran corresponder y puestas en conocimiento del Procurador Público del Ministerio de Defensa, a fin de que en razón de sus competencias evalúe el inicio de las acciones legales correspondientes.

22- Finalmente, debe mencionarse que por todo lo expuesto, no corresponde la entrega de la información petitionado al estar debidamente justificada y sustentado las condiciones por las cuales se encuentra adecuada a la Constitución y las leyes el carácter clasificado de la información.”

Finalmente, en fecha 6 de febrero de 2023 se realizó un informe oral, en la cual únicamente se apersonó el recurrente, quien ratificó el carácter público de lo requerido.

II. ANÁLISIS

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

En este marco, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS², establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones de ley, teniendo las entidades la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

A su vez, el artículo 10 del mismo texto dispone que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Cabe anotar que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser fundamentada por las excepciones de ley, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17 del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental.

Por su parte, el literal f) del numeral 1 del artículo 15 de la referida ley, establece que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la

² En adelante, Ley de Transparencia.

seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

A su vez, el artículo 16 de la Ley de Transparencia refiere el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

En ese contexto, el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM³, señala que cuando se denegara el acceso a la información requerida por considerar que no tiene carácter público, las entidades de la Administración Pública deberán hacerlo obligatoriamente en base a razones de hecho y a las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia.

En esa línea, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que las entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada. Asimismo, que en el registro deberán consignar los siguientes datos: “a. *El número de resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la resolución por la cual se le otorgo dicho carácter; b. El número de la resolución la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida; c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se le da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento que se produzca la correspondiente desclasificación; d. La fecha y la resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda; e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y, f. La fecha y la resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.*”

³ En adelante, Reglamento de la Ley de Transparencia.

Finalmente, el artículo 18 de la Ley de Transparencia establece que las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona.

2.1. Materia en discusión

De autos se advierte que la controversia radica en determinar si la información solicitada por el recurrente se encuentra inmersa en la excepción al derecho de acceso a la información pública prevista en el artículo 15 o el artículo 16 de la Ley de Transparencia.

2.2. Evaluación

Sobre el particular, toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 4865-2013-PHD/TC indicando:

“La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos.”

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Transparencia, que consagra expresamente el Principio de Publicidad, establece que: “Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por (...) la presente Ley”. Es decir, establece como regla general la publicidad de la información en poder de las entidades públicas, mientras que el secreto es la excepción. En esa línea, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD/TC, ha señalado respecto del mencionado Principio de Publicidad lo siguiente:

“(...) Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado”.

Teniendo en cuenta ello, el Tribunal Constitucional precisó que le corresponde a las entidades acreditar la necesidad de mantener en reserva la información que haya sido solicitada por el ciudadano, conforme se advierte del último párrafo del Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC:

“Como antes se ha mencionado, esta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede servir

efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que, si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y, en esa medida, confirmarse su inconstitucionalidad; pero también significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado” (subrayado agregado).

En ese sentido, de las normas legales y los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional antes citados, se infiere que toda información que posean las entidades de la Administración Pública es de acceso público; y, en caso dicha información corresponda a un supuesto de excepción previsto en los artículos 15 a 17 de la Ley de Transparencia, constituye deber de las entidades acreditar dicha condición, debido a que poseen la carga de la prueba.

En el caso de autos, el recurrente solicitó a la entidad “*Tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre en Pichanaki (Junín), en el marco del DS 143-2022-PCM*”.

Por su parte, la entidad denegó la solicitud en base a lo señalado en el Memorándum N° 025 ECMFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, mediante el cual el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que la información requerida se encuentra exceptuada de ser entregada en mérito a lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Frente a ello, el recurrente interpuso su recurso de apelación señalando que la información solicitada es reportada por los miembros de las Fuerzas Armadas conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1095, y además que su divulgación permite fiscalizar la labor de dichos miembros en el marco de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ayacucho, Apurímac y Junín, por lo cual no podrá ser considerada como información clasificada.

A nivel de descargos, el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI, señaló que la información se negó en mérito a que “(...) *Resulta lógico y necesario entonces que, en salvaguarda del éxito de las acciones en apoyo a la misión constitucional de mantener y restablecer el orden interno de nuestra gloriosa Policía Nacional, estas disposiciones y planes mantengan un carácter y condición de clasificadas y reservadas, como para hacerse de conocimiento público per se*”. En dicha línea, indica que, la clasificación en secreta de la información no contraviene la capacidad fiscalizadora, por el contrario, señala que dicha difusión “(...) *implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el manteniendo del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno. que como es sabido viene siendo violentado por un grupo de personas, que una vez identificados, serán denunciados y procesados por el daño que vienen ocasionando al propio Estado, a las personas y a los bienes*”.

Asimismo, agrega que la clasificación de la información se encuentra regulada mediante “*la Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa, la cual dentro de su anexo “1”, sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información RESERVADA según el literal d) del artículo 16 de la ley de la materia, dispone:*

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia, se considera reservada la Información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

01: Adquisición, provisionamiento de armamento, munición y artificios para su empleo en régimen de excepción.

05: Informe de consumo de munición de la Institución.

18.- Del mismo modo, Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la cual dentro de su anexo "1", sobre clasificación y categorización de la documentación relacionadas a la información secreto según el literal e) del artículo 16 de la ley de la materia, dispone:

03: Adquisición, provisionamiento de armamento, munición y artificios para su empleo en régimen de excepción.

05: Informe de consumo de munición de la Institución".

Finalmente, señala que "(...) no puede suponerse menos afirmarse, como temerariamente expresa el peticionante, que las Fuerzas Armadas han cometido actos de violación de Derechos Humanos (...)".

Teniendo en cuenta ello, y en tanto la entidad no negó la existencia de la información solicitada, sino que indicó que tiene carácter secreto o reservado, corresponde determinar si la entidad atendió el pedido del recurrente conforme a ley.

Sobre la clasificación de la información solicitada como secreta

El artículo 15 de la Ley de Transparencia es el que ha establecido la obligación de clasificar expresamente la información que califica como secreta como requisito para restringir el acceso a dicha información:

"Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley".

En la misma línea, el artículo 16 de la Ley de Transparencia refiere que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada.

La obligación de clasificar la información que califica como secreta o reservada se cumple a través de la emisión de una resolución del titular de la entidad que le otorga dicho carácter, la cual a su vez se inscribe en un registro creado especialmente para dicho fin. Al respecto, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia establece lo siguiente:

“Artículo 21.- Registro

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

- a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;*
- b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;*
- c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación; (...)*
(subrayado agregado).

La resolución que clasifica la información no constituye un acto discrecional del titular de la entidad o del funcionario delegado por éste, sino que la misma debe dictarse con base en los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Transparencia, y cumplir con el deber de motivar adecuadamente las razones por las cuales la información califica en alguno de dichos supuestos. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 33 de la sentencia del Pleno Jurisdiccional recaída en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC, en el cual ha precisado que la clasificación de la información no solo debe ser nominal, sino que debe estar adecuadamente motivada en los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Transparencia:

“Como ya se ha explicado antes y así se desprende del respectivo mandato constitucional y legal, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la publicidad de la información financiada por el presupuesto público, de modo que la Administración tiene la obligación de hacer pública tal información. Las excepciones son aquellas expresa y únicamente contenidas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e incluso dichas excepciones se aplican de modo restrictivo y sólo cuando la Administración ha justificado o motivado su clasificación como secreta, reservada o confidencial. Si no se ha justificado debidamente la respectiva clasificación carece de efectos la sola nominación formal (colocación de sellos con las expresiones “secreto” o “reservado”), debiendo en todo caso ser la última instancia administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública la encargada de examinar si la información calificada de secreta o reservada reviste realmente o no tal carácter” (subrayado agregado).

De las normas y la jurisprudencia citadas se desprende que cuando una entidad alega que determinada información no puede entregarse por encontrarse clasificada como secreta o reservada, la misma se encuentra en la obligación de acreditar la existencia de la resolución que clasifica expresamente dicha información como secreta, así como de comunicar el sustento con base en el cual se considera que la información solicitada se encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en los artículos 15 o 16 de la Ley de Transparencia, no bastando para ello la alusión genérica a dichos preceptos normativos, sino que es necesario que se especifiquen las razones por las cuales la documentación solicitada cumple con los distintos elementos que componen la excepción invocada.

Asimismo, conforme lo dispuesto por el citado artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia, la clasificación de la información como secreta o reservada también debe cumplir con determinados requisitos formales, como su aprobación por el titular del sector o pliego o por un funcionario designado por este para dicho fin, mediante una resolución debidamente motivada, la cual debe registrarse con un número, fecha de emisión, y señalando la denominación del documento clasificado y su código.

En el caso de autos, esta instancia aprecia que si bien la entidad ha alegado que la información se encuentra clasificada como secreta y reservada, solo ha referido que la entidad clasifica la información según la *Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa* y la *Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas*; sin embargo, dichos instrumentos normativos internos simplemente constituyen una guía que regula el procedimiento para la clasificación, mas no corresponde a una resolución que clasifica determinada información.

De este modo, la entidad no ha acreditado con ningún documento la aludida clasificación, pese a que, como ya se señaló, la clasificación de información secreta o reservada tiene determinadas formalidades, como que la misma haya sido aprobada mediante una resolución del titular del sector o pliego, o funcionario designado por éste, y que la misma se encuentre consignada en el registro correspondiente, y en el cual se especifique la fecha de la resolución de clasificación, la denominación de la información clasificada y su código, siendo que ninguna de dichas formalidades han sido acreditadas por la entidad en el presente caso.

En consecuencia, la entidad no ha cumplido con el requisito legal de la clasificación de la información como secreta o reservada para denegar el acceso a la información solicitada.

Sobre la motivación para calificar la información como secreta

No obstante lo anteriormente señalado, la entidad brindó respuesta al administrado señalando que la información solicitada calificaba como secreta, invocando para ello el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pero sin precisar la sub causal específica en la cual encajaban los documentos requeridos, con lo cual infringió su deber de motivar adecuadamente la denegatoria de la información.

Sin embargo, en los descargos presentados a esta instancia la entidad ha aducido que la información solicitada se encontraría inmersa en el literal “e” del numeral 1 del artículo 16 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la aludida norma establece que:

“Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

(...) e) *El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno*” (subrayado agregado).

En dicho contexto, en el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI, emitido por el Jefe de la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la entidad ha señalado que lo solicitado se refiere a la *“01. Adquisición, provisionamiento de armamento, munición y artificios para su empleo en régimen de excepción. 05: Informe de consumo de munición de la Institución”*, conforme a lo regulado en la Directiva General 01 MINDEF/SG/G Normas para garantizar la seguridad de las informaciones en el Ministerio de Defensa y la Directiva General 022-21/JCCFFAA/SJ Directiva para normar los procedimientos para el acceso, clasificación, archivo y conservación de la documentación en el Comando Conjunto de las fuerzas Armadas, con base en el literal e) del numeral 1 del artículo 16 de la Ley de Transparencia, añadiendo que la eventual revelación de la información *“(…) implicaría el posible y previsible hecho que no pudieran tener éxito las acciones que el Estado despliega para el mantenimiento del Estado de Derecho y restablecimiento del orden y la paz social a nivel del orden interno (...)”*. Asimismo, ha precisado que *“la eficacia y eficiencia de las acciones devienen de su buena ejecución y carácter de reservado, en la obtención del objetivo deseado, siendo que su difusión y entrega significa un riesgo latente en contrario”*, más aun cuando la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional continúa en algunas regiones del país.

Al respecto, como ya se ha establecido en la presente resolución, para la denegatoria de una solicitud de acceso a la información pública la entidad debe brindar una motivación suficiente que precise con claridad que la información requerida encaja en los distintos elementos que componen una excepción. En el caso de autos, es preciso destacar, en primer lugar, que la entidad ha brindado una motivación distinta de la denegatoria de información, pues mientras en su respuesta ha aludido al artículo 15 de la Ley de Transparencia (referida a información secreta del ámbito militar), en sus descargos ha invocado el literal e) del numeral 1 del artículo 16 de la referida ley (referida a información reservada del ámbito policial).

Sobre el particular, esta instancia considera necesario indicar que habiéndose requerido información sobre armamento utilizado por las Fuerzas Armadas, en estricto, el supuesto de excepción en entredicho sería el contemplado en el literal f) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, relativo al *“material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas”*.

Sobre dicha excepción, la entidad debía brindar una motivación suficiente, lo que implicaba acreditar dos supuestos que apareja la excepción invocada: a) primero, que la información requerida se refiere a material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación; y b) segundo, que la revelación de dicha información afectaría la seguridad nacional, la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, o perjudicaría las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI, o los planes de defensa militar.

A este respecto, la entidad en la respuesta brindada al ciudadano no ha expuesto ninguna justificación, pues solo ha citado el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Y cuando se ha referido al artículo 16 de la citada ley, solo ha dicho de modo genérico que la información se refiere a provisionamiento de armamento y consumo de municiones y que ello podría afectar el éxito de las operaciones para recuperar el orden interno. Sin embargo, la entidad no ha detallado de qué modo la divulgación de la información solicitada afectaría la eficacia o el éxito de dichas operaciones, más aun cuando la información se refiere a armas utilizadas en operaciones ya ejecutadas, mas no en operaciones por ejecutarse.

Sobre el particular, es preciso destacar que los documentos solicitados fueron documentos que la entidad debió elaborar en el contexto de la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional, establecido por el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, publicado el 14 de diciembre de 2022, en el cual se señaló:

“(…) Artículo 1.- Declaratoria de Estado de Emergencia

Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

(…)

Artículo 3.- Suspensión de los Estados de Emergencia vigentes a nivel nacional

Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, queda suspendida la vigencia de los Estados de Emergencia declarados en distintos departamentos del país, en los cuales la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo del control del orden interno.

Artículo 4.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente”.

Es decir, mediante el aludido decreto supremo se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno, disponiendo que su actuación se regulaba por el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional⁴, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE⁵.

En dicho contexto, es el numeral 1 del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1095, el que establece la obligación de la entidad de generar información relacionada con el uso de armas de fuego en el marco de una operación militar: “Los miembros de las Fuerzas Armadas que hagan uso de armas de fuego presentan en el término de la distancia un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: fecha, hora y lugar del incidente, unidad o elemento que participó en el incidente, hechos que condujeron a su participación, la causa por la cual se abrió fuego, el tipo y la cantidad de armas y municiones empleadas, daños personales o materiales causados, número de eventuales detenidos, heridos o muertos, debiendo acompañar, en lo posible, registros filmicos o fotográficos existentes” (subrayado agregado).

⁴ En adelante, Decreto Legislativo N° 1095.

⁵ En adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095.

Ahora bien, es necesario resaltar en este punto que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para el restablecimiento del orden interno en el contexto de un Estado de Emergencia, debe efectuarse en respeto del marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así lo ha establecido el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1095, el cual expresamente prescribe:

“5.2 Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia se orienta a realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional para el control del orden interno, rigen las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

En dicha línea, el artículo 16 del aludido decreto legislativo establece que los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: son los de legalidad, necesidad y proporcionalidad⁶.

Asimismo, el artículo 18 de la referida norma ha previsto que la fuerza debe ser utilizada de modo progresivo según las circunstancias del caso concreto, esto es en el marco de niveles de uso de la fuerza como son el nivel preventivo (involucra la presencia militar, el contacto visual y la verbalización) y posteriormente y previa advertencia cuando se han agotado las acciones preventivas, el nivel reactivo (que involucra el control físico, el uso de medios no letales y uso de medios letales)⁷.

Del mismo modo, la norma en cuestión en su artículo 19 también ha previsto las circunstancias excepcionales en las cuales pueden utilizarse armas de fuego, destacando que su uso solo puede justificarse en la protección de la vida o la integridad física del propio personal militar o de alguna otra persona, y ello por cuanto la posibilidad de afectar la vida e integridad física con el empleo de un arma de fuego solo puede estar justificado en la salvaguarda de un bien jurídico de la misma importancia⁸.

⁶ “a. **Legalidad.**- El uso de fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas debe estar amparado en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento.

b. **Necesidad.**- El análisis de la necesidad en cuanto al uso de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas implica dos verificaciones: (i) haber agotado el despliegue de medidas que no implican el uso de la fuerza y que permitiesen alcanzar el resultado esperado; y, (ii) luego de esta verificación, llegar a la conclusión de que un eventual uso de la fuerza resulta inevitable para alcanzar dicho resultado.

c. **Proporcionalidad.**- Es la equivalencia o correspondencia entre la gravedad de la amenaza y el grado de fuerza empleada, debiendo ser ésta la mínima necesaria en relación a dicha amenaza y en función al resultado legal esperado”.

⁷ “Artículo 18.- Niveles de uso de la fuerza

18.1.Preventivo

a. **Presencia Militar.**- Es la demostración de autoridad, en la que los miembros de las Fuerzas Armadas están uniformados, equipados, en actitud diligente y de alerta, actuando preventiva y disuasivamente a fin de mantener o restablecer el orden interno.

b. **Contacto Visual.**- Es el dominio visual sobre una persona, grupo de personas, vehículos, áreas o instalaciones, que permite ejercer un cierto control sobre la situación.

c. **Verbalización.**- Es el uso de la comunicación oral, utilizando el tono y los términos necesarios que sean fácilmente comprendidos, con miras a mantener o restablecer el orden interno.

18.2 Reactivo

Agotadas las acciones del nivel preventivo y antes de usar la fuerza en el nivel reactivo, se realiza la advertencia correspondiente, procediendo al uso de la fuerza gradualmente, siempre y cuando la situación lo permita, de la manera siguiente:

a. **Control físico.**- Es la acción militar que utiliza técnicas de fuerza corporal, con el fin de controlar, reducir, inmovilizar o conducir ante la autoridad que corresponda a quienes se encuentren alterando el orden interno.

b. **Medios no letales.**- Se refiere al empleo de equipamiento y armas con bajo potencial de daño, para contrarrestar o superar la amenaza existente.

c. **Medios letales.**- Excepcionalmente, se puede proceder al empleo de armas de fuego, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 19 del presente Decreto Legislativo”.

⁸ “Artículo 19.- Uso excepcional

19.1 Excepcionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la misión asignada pueden usar armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en

En dicho escenario, la intervención de las Fuerzas Armadas en el contexto del restablecimiento del orden interno no conlleva una actuación discrecional, sino que la misma se encuentra claramente reglada, en salvaguarda de evitar sacrificios innecesarios de la vida o la integridad física que puedan producirse como consecuencia del uso de la fuerza que ejecute el personal militar. Tal es la finalidad de someter el uso de la fuerza al Derecho y de tutelar con ello la vida de las personas, que las normas aquí citadas incluso han previsto la rendición de cuentas por parte del personal militar cuando se efectúe en el seno de una operación militar el empleo de la fuerza letal, pues además del informe contemplado en el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1095, al que ya se hizo referencia, el artículo 31 de dicha norma establece que el comandante a cargo de la operación debe presentar un informe de las incidencias ocurridas durante la operación ejecutada:

“Artículo 31.- Presentación de informe

Concluidas las operaciones o acciones previstas en el presente Decreto Legislativo, el comandante de la fuerza militar presenta un informe por escrito a su superior, dando cuenta de los siguientes aspectos: fecha, hora y lugar de las operaciones o acciones, unidad o elemento participante, hechos que condujeron a su participación, las operaciones o acciones efectuadas, sus resultados y otros aspectos de relevancia”.

Finalmente, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095 en los numerales 45.7 y 45.8 ha previsto incluso la posibilidad de acceder a información sobre operaciones militares en las cuales se haya hecho uso de la fuerza, a través de un procedimiento de acceso a la información pública:

“Artículo 45.- Procedimientos como consecuencia del empleo o uso de la fuerza

(...)

45.7 Los pedidos de información o documentación sobre una operación o acción militar son atendidos por la entidad correspondiente de acuerdo a la normativa vigente sobre transparencia y acceso a la información pública.

45.8 Toda persona tiene derecho a recibir información completa, veraz y oportuna sobre las personas heridas o fallecidas como consecuencia de una operación o acción militar, así como sobre las personas que hayan sido intervenidas (...) (subrayado agregado).

Esta norma no califica pues la información sobre una operación militar ejecutada en la cual se haya hecho uso de la fuerza como secreta, sino que deriva el tratamiento de los pedidos de información sobre dicha materia a la Ley de Transparencia, lo que conlleva a presumir el carácter público de dicha información, y a restringir su acceso solo en determinados supuestos tasados en las excepciones, y bajo una interpretación restrictiva de las mismas.

caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

19.2 Si como consecuencia del uso de las armas de fuego se produjeran heridos, los miembros de las Fuerzas Armadas habilitan la atención médica inmediata, sin discriminación. En caso de que se registren personas fallecidas se adoptan los protocolos correspondientes para el tratamiento de los restos humanos. En ambos casos, se procede a informar a los familiares”.

En dicha línea, es pertinente destacar que el Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en el Expediente N° 02814-2008-PHD ha establecido que una de las funciones esenciales del acceso a la información pública es la posibilidad de fiscalizar el ejercicio de la función pública por parte de funcionarios y servidores públicos:

“Uno de los elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho es la responsabilidad de los funcionarios. Ello implica una capacidad fiscalizadora importante por parte de la población a fin de controlar a los funcionarios y servidores públicos, idea central o nuclear del sistema democrático. Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado. Como ya se dijo en la STC 04912-2008-HD/TC, el tener acceso a los datos relativos al manejo de “la res pública resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que pueda fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes” (fundamento 3)” (subrayado agregado).

En el caso de autos, la información sobre el armamento y municiones empleados en un operativo militar en la medida que permite escrutar que el ejercicio de la función pública –que incluye la actuación del personal militar- se realizó conforme a ley es información de naturaleza pública, que solo puede quedar restringida con base en un supuesto de excepción específico y siempre que se acredite que su divulgación puede afectar el bien jurídico protegido por dicha excepción, y que la protección de dicho bien resulta más importante que el acceso a la información pública en el caso concreto (principio de proporcionalidad).

En el presente procedimiento, sin embargo, la entidad no ha cumplido su obligación de motivar adecuadamente que nos encontremos en un supuesto de información secreta, pues si bien la información sobre armamento se encuentra descrita en el literal f) del numeral 1 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, la entidad no ha justificado cómo la revelación de dicha información puede afectar la seguridad nacional, la seguridad personal, la integridad territorial o la subsistencia del sistema democrático, o los planes de defensa militar, tratándose de información relativa a operaciones militares ya ejecutadas.

La entidad en su respuesta al pedido de información no brindó al administrado ninguna justificación adecuada de la denegatoria, pues solo citó el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y tampoco ha subsanado dicha omisión brindando a esta instancia una motivación suficiente de dicha denegatoria, por lo que la presunción de publicidad sobre la información requerida se mantiene.

Adicionalmente a ello, esta instancia debe enfatizar que el derecho de acceso a la información pública, además de permitir el escrutinio del ejercicio de la función pública, sirve también para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En ambos campos su ejercicio resulta trascendente. Por ello su limitación no solo debe basarse en la invocación de una excepción, sino que es preciso que se justifique, en base al principio de proporcionalidad, que la divulgación de información afecta el bien jurídico protegido por la excepción y que la protección de dicha información resulta más importante que el acceso a la misma en las circunstancias del caso concreto.

En dicho contexto, en el supuesto que se estableciera que la información solicitada estuviera relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, la Ley de Transparencia le otorga a la misma una protección máxima en cuanto a su publicidad, pues el último párrafo de su artículo 18 ha previsto que no puede clasificarse como secreta o reservada:

“Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú”.

Lo que supone que en el caso en que exista una vinculación entre la información requerida y el conocimiento de las circunstancias, causas y responsables de hechos que califican como graves violaciones a los derechos humanos, la mencionada información goza de un marco de máxima publicidad.

En dicho contexto, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 2488-2022-HC/TC, el derecho a conocer la verdad de lo sucedido en casos de graves violaciones a los derechos humanos no solo constituye un derecho de las víctimas de dichas violaciones, sino que dicho derecho a la verdad cuenta también con una dimensión colectiva, en virtud a la cual la sociedad en conjunto “(...) tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.

Bajo este marco explicativo, para este Tribunal resulta claro que la prohibición de clasificar como secreta o reservada la información relacionada a graves violaciones a derechos humanos tiene su fundamento en el derecho a la verdad. Tratándose de daños graves a la dignidad humana, que socavan el modelo mismo de Estado Constitucional y Democrático de Derecho, el interés en el conocimiento de la información sobre dichas violaciones a los derechos humanos es general. La máxima publicidad de dicha información garantiza, además, la vigilancia sobre las investigaciones adelantadas por los Estados para la determinación de responsabilidades por dichos hechos.

En dicho contexto, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia, en el supuesto que la información solicitada (en el presente caso, sobre el armamento y municiones utilizados el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín)) se encontrara relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier persona, en cualquier circunstancia, la misma no puede ser clasificada como reservada, secreta o confidencial.

En consecuencia, corresponde estimar el recurso de apelación y ordenar a la entidad que entregue la información pública requerida por el recurrente.

Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, en aplicación de

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia, señala que todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma y que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 376 del Código Penal.

Además, el artículo 368 del Código Penal establece que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Por los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 y en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses; asimismo, ante la abstención formulada por la Vocal Titular Silvia Vanesa Vera Muelle declarada fundada⁹ anteriormente y el orden de prelación establecido en la Resolución N° 031200212020 de fecha 13 de febrero de 2020, interviene la Vocal Titular de la Primera Sala María Rosa Mena Mena.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación presentado por **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** contra la respuesta contenida en el Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, en consecuencia, **ORDENAR** al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** que entregue la documentación solicitada, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, de acuerdo a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, en atención a lo dispuesto por los artículos 368 y 376 del Código Penal.

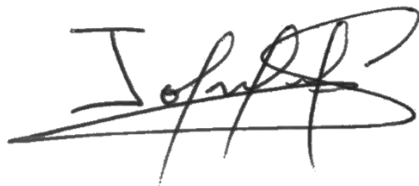
Artículo 2.- SOLICITAR al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS** que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, acredite a esta instancia la entrega de dicha información al recurrente **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA**.

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley N° 27444.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a **ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA** y al **COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la norma antes citada.

⁹ Conforme a lo resuelto en la Resolución N° 2323-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA de fecha 8 de noviembre de 2021.

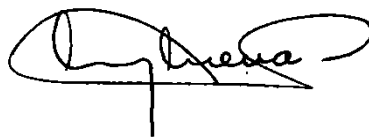
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe).



JOHAN LEÓN FLORIÁN
Vocal Presidente



VANESSA LUYO CRUZADO
Vocal



MARIA ROSA MENA MENA
Vocal

vp: fjlf/jmr